

1507282-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... capaz de distinguir consumo pessoal e tráfico de drogas" em relação à maconha.

A questão, evidentemente, será retomada com o voto dos outros ministros que compõem o Tribunal, mas, ao menos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com repercussão geral, é inescapável o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em controle difuso.

A criminalização do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507282-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507282-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083485/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23877577 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2083485 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR SAMUEL DE ALMEIDA BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou VITOR SAMUEL DE ALMEIDA BISPO, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal; art. 157, § 2º II, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal; art. 28, caput, da lei n. 11343/06.

A inicial acusatória contém a exposição do seguinte fato criminoso:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 26 de março de 2022, por volta de 05h00min, nas imediações da Rua da Consolação, nesta cidade e comarca da Capital, VITOR SAMUEL DE ALMEIDA BISPO, qualificado nos autos, agindo em concurso com o adolescente Guilherme Pietro Gomes Simões, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência, um telefone celular Apple iPhone 11, pertencente a Victor Fernando Cabieses Boucinha da Silva. Consta também que, no dia 26 de março de 2022, por volta de 5h00min, nas imediações da estação de metrô República, nesta cidade e comarca da Capital, VITOR SAMUEL DE ALMEIDA BISPO, qualificado nos autos, agindo em concurso com o adolescente Guilherme Pietro Gomes Simões e outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência, um telefone celular Apple iPhone 11, pertencente a Leonardo da Silva Quaresma, e um

telefone celular Samsung A23, pertencente a Vinicius Arthur da Silva Teixeira. Consta, finalmente, que, no dia 26 de março de 2022, por volta de 7h52min, na Avenida São João, altura do numeral 83, nesta cidade e comarca da Capital, VITOR SAMUEL DE ALMEIDA BISPO, qualificado nos autos, trazia consigo, para consumo pessoal, um invólucro plástico contendo 2,1 gramas de maconha, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação provisória a fls. 54/57). Segundo se apurou, o ofendido Victor caminhava pela via pública quando o denunciado e o comparsa adolescente o abordaram por trás e o jogaram no chão. Em seguida, eles subtraíram seu telefone celular, evadindo-se. Apurou-se, ainda, que os ofendidos Leonardo e Vinicius caminhavam pela via pública quando o denunciado e o comparsa adolescente se aproximaram por trás e lhes deram um golpe tipo “gravata”. Em seguida, outros indivíduos se juntaram a VITOR e ao adolescente e todos subtraíram os telefones celulares das vítimas, evadindo-se. Ocorre que a vítima Victor passou a monitorar a localização de seu telefone celular através do GPS e informou o local apontado a policiais militares, os quais, em diligências, abordaram o denunciado e o adolescente. Após revista pessoal, os agentes públicos localizaram, em poder do adolescente, os telefones celulares subtraídos e, em poder de VITOR, uma porção de maconha. Victor reconheceu o denunciado e o adolescente como autores do crime (fl. 33) e Vinicius reconheceu apenas o denunciado (fl. 31). Os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas.” A denúncia foi recebida em 19/04/2022 (fls. 143/145). O acusado foi regularmente citado (fl. 185) e apresentou resposta à acusação (fls. 191/192).

Seguiu-se a instrução probatória com as declarações das vítimas, inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, além da imposição da sanção de advertência para o crime de porte de drogas para uso próprio.

A defesa requereu a absolvição, com fundamento na fragilidade da prova e, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal e imposição de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório. DECIDO.

1.1. Inicialmente, forçoso o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, da intervenção mínima, lesividade e, ademais, às garantias constitucionais da privacidade e da intimidade.

A questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 635.659, com repercussão geral reconhecida e, até o momento, os três ministros que proferiram voto declararam, em maior ou menor extensão, a inconstitucionalidade desse dispositivo.

O Ministro GILMAR MENDES votou no sentido de “declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de forma a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal” .

O Ministro EDSON FACHIN, em posicionamento mais restrito, votou no sentido de “declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343, sem redução de texto, específica para situação que, tal como se deu no caso concreto, apresente conduta que descrita no tipo legal tiver exclusivamente como objeto material a droga aqui em pauta <>”.

O Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, por sua vez, votou no sentido de declarar inconstitucional “a tipificação das condutas previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, que criminalizam o porte de drogas para consumo pessoal” e ainda apontou “parâmetro objetivo capaz de distinguir consumo pessoal e tráfico de drogas” em relação à maconha.

A questão, evidentemente, será retomada com o voto dos outros ministros que compõem o Tribunal, mas, ao menos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com repercussão geral, é inescapável o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em controle difuso.

A criminalização do consumo de drogas é incompatível com os objetivos estabelecidos

pela própria lei de drogas, que estabelece, logo em seus primeiros artigos, medidas de prevenção, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Longe de permitir a consecução desses objetivos, o tratamento do usuário como criminoso, e a consequente atuação do sistema de justiça criminal, incluídas as agências policiais, acarretam estigmatização, degradação e rompimento de vínculos comunitários, justamente o que a lei busca impedir.

A possibilidade de imposição de pena, ainda que abrandada, não aproxima o usuário do tratamento; ao contrário, afasta-o, porque significa confissão de culpa criminal e sujeição à violenta atuação de órgãos de repressão.

Se a criminalização (meio) está em confronto com os objetivos declarados da lei (fim), é forçoso reconhecer excesso legislativo por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Além de ofensa à regra da proporcionalidade, o tratamento do usuário de drogas como criminoso envolve um juízo exclusivamente moral, que é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e representa indevida ingerência estatal na esfera da intimidade, que tem evidente proteção constitucional.

Não se trata de punir uma grave violação a direito alheio, que é a essência do direito penal, mas um comportamento meramente inadequado, incorreto e até censurável, contudo, sem relevância jurídica para fins de política criminal.

Por fim, o argumento de ofensa à saúde pública ao qual se apegam os defensores da criminalização é falacioso, porque o Estado tolera o consumo de outras drogas, como o álcool e o tabaco, a um custo humano e financeiro muitíssimo superior ao despendido com drogas ilícitas.

A atuação do Estado em relação a drogas ilícitas não deve diferir das medidas desestimuladoras atualmente adotadas em relação ao álcool e ao tabaco, como publicidade negativa, regulação e até tributação, de toda forma sem utilização de órgãos de repressão penal, já que nessa área encontra-se o Estado jungido aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

A criminalização do usuário de drogas revela hipocrisia e moralismo desmedido, que ofendem diversos preceitos constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, na perspectiva de garantia da personalidade e proibição de (desproporcional) ingerência estatal na esfera privada da cidadania.

1.2. Em relação aos crimes de roubo, não se desincumbiu o Ministério Público do ônus probatório, de forma que a denúncia em relação a esse delito é improcedente. Todos aqueles elementos de convicção produzidos no inquérito policial, que permitiram o recebimento da denúncia, não se confirmaram em juízo, o que deve resultar na absolvição do acusado.

As vítimas descreveram os fatos, como consta da denúncia, mas nenhuma delas reconheceu o acusado como autor dos fatos.

Afirmaram em um uníssono que havia vários criminosos e receberam uma “gravata por trás”, o que dificultou o reconhecimento.

As vítimas tentaram efetuar o reconhecimento de tatuagens que o assaltante possuiria no braço direito, mas se confundiram e apontaram equivocadamente um dos figurantes colocados ao lado do acusado para o ato de reconhecimento.

O acusado e o figurante, que foi equivocadamente reconhecido, tinham tatuagens no braço direito, mas com desenhos bastantes distintos e nem mesmo assim se fez possível o reconhecimento correto.

Além disso, o acusado tem uma tatuagem destacada acima da sobancelha direita e outra no lado direito do pescoço, o que poderia chamar a atenção de alguma das vítimas, mas nenhuma delas relatou essa circunstância.

Os policiais militares afirmaram que nenhum objeto roubado foi encontrado com o acusado e o adolescente prontamente assumiu a autoria delitiva, ao passo que o acusado permaneceu em silêncio.

O acusado não foi reconhecido em juízo por nenhuma das vítimas e não portava nenhum objeto roubado, resumindo-se a prova acusatória ao fato dele estar em companhia de um dos roubadores (o adolescente), portar-se de forma suspeita (mudar a direção com a chegada de policiais) e, por fim, ter sido reconhecido na fase policial.

Nenhum desses elementos de convicção, ainda que gerem desconfiança e suspeita de autoria, são suficientes para a condenação e não permitem excluir – com segurança –

a hipótese de erro judiciário.

Em relação ao reconhecimento feito na fase policial, não posso deixar de observar que as vítimas afirmaram em juízo que tiveram dificuldades em ver o rosto dos criminosos, pois receberam uma “gravata por trás” e os fatos ocorreram por volta de 05h, ainda com baixa claridade, o que torna duvidoso o reconhecimento feito em sede policial, não se podendo descartar sugestionamento, ainda que involuntário.

Por último, é certo que o acusado relatou versão inverossímil no interrogatório de que estava no local comprando fraldas para o filho, mas não se pode condená-lo apenas porque apresentou uma justificativa fantasiosa – sim, fantasiosa, pois nenhum pacote de fraldas foi apreendido e não houve questionamento dessa circunstância aos policiais militares, o que somente foi aventado no interrogatório.

Ocorre que é dever do Estado provar a culpa do acusado, em observância ao devido processo legal, e não dele de apresentar uma versão coerente, pressupondo a culpa caso não o faça.

O contexto probatório, mesmo depois de encerrada a instrução, é ainda nebuloso e a absolvição é a única medida possível

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a PRETENSÃO ACUSATÓRIA para o fim de ABSOLVER V.S.D.A.B., qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no art. 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal.

Publique-. Intime-se.

São Paulo, 08 de julho de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA – Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA